

第27問

甲、乙及び丙は、同じ建築会社に勤める建築作業員であり、2階建ての家を建築中であった。この建築に当たっては、一番のベテランである甲が現場監督を務め、その指示に従って、乙及び丙が作業を進めていた。乙は中堅社員であり、建築に当たって全般的な作業を担当していたが、丙はまだ建築作業員になって日が浅いこともあり、木材を運ぶなどの補助的な作業しかしていなかった。建築作業も終盤に差し掛かったある日、乙が、甲の指示により、2階部分に登って、瓦を葺いていた。丙は、甲の指示に従い、瓦を2階部分へと運ぶ作業をしていた。乙は、自己の不注意で、丙が運んで積み上げられていた瓦を路上へ落下させてしまい、路上を歩いていたAが全治1か月の怪我を負った。なお、瓦は、乙が注意を払って取り扱っていれば落下等の危険のない状態で積み上げられていた。

甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。

第1 乙の罪責

乙は、自己の不注意によって、2階から瓦を落下させることでAに怪我を負わせているから、業務上過失致傷罪（211前段）の罪責を負うことは明らかである（**論点** 過失犯の構造  司H22）。

 総合 40 頁  論証 10 頁

第2 甲の罪責

- 1 Aの怪我は、甲自身の過失行為によるものではないから、過失の共同正犯（60）の問題を検討することになる（**論点** 過失の共同正犯  司H22）。
- 2 (1) この点について、行為共同説からはもちろん、犯罪共同説からも「共同の注意義務に共同して違反すること」を実行行為と捉えて、過失の共同正犯を肯定する立場が有力である（東京地判平4.1.23）。判例（最決平28.7.12【百選179】）も、「業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには、共同の業務上の注意義務に共同して違反したことが必要であると解される」としており、この立場に立つと解される。
- (2) もっとも、最決平28.7.12【百選179】は、共同注意義務の共同違反が問題となった者の地位・立場の相違から分担する役割が相違すること、結果回避のために要求され得る行為が相違することの2点を指摘して、これを否定した。そのため、どのような場合に、共同注意義務の共同違反が認められるのか明らかではないが、共同義務につき、基礎となる役割と義務内容いずれの側面でも共同との評価ができれば、共同正犯は肯定可能だろう。
- (3) 本問では、甲及び乙は、同じ建築会社に勤める建築作業員であり、共同して家の建築作業に当たっていたこと、乙は中堅社員であり、甲の指示に従って建築に当たって全般的な作業を担当していたこと、上記乙の行為は、甲の指示により、2階部分に登って瓦を葺いていた際に行われたものであること等の事情を考慮する必要があるが、結論としては、共同注意義務の共同違反を認定して、業務上過失致傷罪の共同正犯を肯定することができるだろう。
- 3 また、甲は現場監督であるから、監督義務違反を認定して、単独犯とすることもできるだろう。

 総合 145 頁  論証 57 頁

第3 丙の罪責

- 1 丙は、まだ建築作業員になって日が浅く、木材を運ぶなどの補助的な作業しかしていなかった。このことから、共同の注意義務を認めることはできない。
- 2 また、瓦は、乙が注意を払って取り扱っていれば落下等の危険のない状態で積み上げられていたのであるから、この点に関する丙の過失も認められない。
- 3 したがって、丙は業務上過失致傷罪の罪責を負わない。

答案構成

第1 乙の罪責

- 1 業務上過失致傷罪（211前段）の成否

↓

- 2 「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、かつその行為が他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるものをいう

↓

あてはめ

↓

「注意を怠」った

↓

新過失論

↓

あてはめ

↓

- 3 乙は業務上過失致傷罪の罪責を負い、甲と共同正犯（60）となる

第2 甲の罪責

- 1 業務上過失致傷罪の共同正犯の成否

↓

- 2 共同の注意義務に共同して違反した場合には、共同正犯が成立

↓

あてはめ

↓

- 3 甲には、業務上過失致傷罪の共同正犯が成立する

第3 丙の罪責

- 1 共同の注意義務は認められない

↓

過失の共同正犯は成立しない

↓

- 2 単独犯も成立しない

↓

- 3 丙は業務上過失致傷罪の罪責を負わない

第1 乙の罪責

1 乙は、建築会社に勤める建築作業員であるところ、建築作業中、自己の不注意で、丙が運んで積み上げられていた瓦を路上へ落下させてしまい、路上を歩いていたAが全治1か月の怪我を負っているから、「業務上必要な注意を怠り、よって人を」負「傷させた」ものとして、業務上過失致傷罪（211条前段）が成立し得る。

2(1) 「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、かつその行為が他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうところ、乙の建築作業員としての地位に基づく建築作業はこれに当たる。

(2) 「注意を怠」ったこと、すなわち、過失とは構成要件要素及び違法要素であるから、予見可能性を前提とする予見義務違反及び、結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反と解すべきである。

本問では、2階から建築資材が落下することにより路上を通行する者の身体・生命に危険が及ぶことは十分予見可能であり、予見すべき義務があった。また、乙が、2階部分に登って、瓦を葺く際に路上へ落下しないように十分注意するなどして作業を行えば、上記結果は回避できたし、乙は建築会社に勤める建築作業員であり、中堅社員であること、建築に当たって全般的な作業を担当していたことを考慮すれば、乙は結果を回避すべき義務を負っていたといえる。にもかかわらず、そのような義務を果たさず、瓦を路上へ落下させているから、結果回避義務違反も認められる。

1

3 したがって、乙は業務上過失致傷罪の罪責を負い、後述のとおり甲と共同正犯（60条）となる。

第2 甲の罪責

1 本件で実際に瓦を落下させたのは乙であるが、乙は現場監督である甲の指示に従っていたのであるから、甲について「共同して犯罪を実行した」として、業務上過失致傷罪の共同正犯が成立することが考えられる。

2(1) もっとも、共同正犯の処罰根拠である一部実行全部責任の本質は、相互利用補充関係に基づく共同犯行の一体性に求められるのであり、そうだとすれば、無意識的な過失犯を共同して犯すことは不可能であるとも考えられる。

しかし、過失犯の本質は、上記のような結果回避義務違反である。すなわち、過失犯の実行行為は、かかる義務を怠る点に求めることができる。そして、共同の注意義務に共同して違反することは可能である。

よって、自説の立場から、そのような関係性が認められれば、「共同して犯罪を実行した」として、過失犯の共同正犯を認めることができる。

(2) 本問では、甲及び乙は、同じ建築会社に勤める建築作業員であり、共同して家の建築作業にあたっていたのだから、少なくともその作業の過程で人の身体の安全に十分注意して作業をすべき義務を負っていたといえる。

2

また、甲は現場で一番のベテランであり、現場監督を務め、その指示に従って、中堅社員である乙が建築に当たって全般的な作業を担当しており、実際に、乙の上記過失行為は、甲の指示により、2階部分に登って瓦を葺いていた際に行われたものである。

このような事実からすれば、甲及び乙は、建築工事に付随する落下物防止などの乙の作業上発生する危険を共同して防止する関係が認められるといえる。

以上からすれば、甲及び乙に、共同の注意義務が存在していたといえ、同義務に共同して違反したといえる。

3 したがって、甲には、業務上過失致傷罪の共同正犯が成立する。

第3 丙の罪責

1 丙についても、業務上過失致傷罪の共同正犯の罪責を負うか問題となる。

確かに、丙も、同じ建築会社に勤める建築作業員であり、共同して家の建築作業にあたっていたものである。

しかし、丙は、まだ建築作業員になって日が浅いこともあり、木材を運ぶなどの補助的な作業しかしていなかった。このことからすれば、丙については、瓦を2階部分へと運び積み上げる際にそれが落下しないように注意すべき義務はあるといえるが、乙の作業上発生する危険を共同して防止する義務までは認められないと考えられる。

したがって、共同の注意義務を認めることはできない。

2 また、瓦は、乙が注意を払って取り扱っていれば落下等の危険のない

3

状態で積み上げられていたのであるから、瓦を2階部分へと運び積み上げる際にそれが落下しないように注意すべき義務に違反したとも言えない。

3 したがって、丙は業務上過失致傷罪の罪責を負わない。

以上

4